

1503584-78.2021.8.26.0482

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... e Fabiano Robles de Lima pelo crime de tráfico de drogas.

É cediço que no processo penal por tráfico, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1503584-78.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503584-78.2021.8.26.0482

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2239994/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 14436491 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 8, 127/21/587 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 2239994 - 2ª ENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

FABIANO ROBLES DE LIMA e outro

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de FABIANO ROBLES DE LIMA e DOUGLAS RICARDO DE OLIVEIRA, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 24 de agosto de 2021, em horário incerto, na Rua Benedito Jandiro Soares, nº 945, Vila Santista Cipó, na Agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Bairro do Cipó, no município de Embu-Guaçu/SP, o denunciado FABIANO ROBLES DE LIMA, previamente ajustado, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o denunciado DOUGLAS RICARDO DE OLIVEIRA, remeteu droga às dependências da Penitenciária Wellington Rodrigo Segura de Presidente Prudente, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em 08

(oito) porções de Cannabis Sativa Lineu, com peso líquido total aproximado de 301,27g (trezentos e um grama e vinte e sete centigramas).

Consta que em data incerta, mas anterior ao dia 30 de agosto de 2021, no período vespertino, na Estrada Irio Zuntini, km 4, Conjunto Habitacional João Domingos Netto, nas dependências da Penitenciária Wellington Rodrigo Segura de Presidente Prudente, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado DOUGLAS RICARDO DE OLIVEIRA, previamente ajustado, agindo com unidade de designios e identidade de propósitos com o denunciado FABIANO ROBLES DE LIMA, adquiriu a droga supra descrita, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o Ministério Público, em data incerta, mas anterior ao dia 30 de agosto de 2021, o denunciado DOUGLAS previamente ajustado com o seu companheiro FABIANO adquiriu as drogas acima mencionadas, que foram entregues ao último.

Em evidente divisão de tarefas, FABIANO dirigiu-se à agência dos correios da AGC - Bairro do Cipó, localizada em Embu-Guaçu/SP, portando o embrulho fotografado, o qual continha 08 (oito) porções de maconha misturadas com biscoito no interior de um pacote, e remeteu-os, via sedex nº QB 41802171 3 BR, para as dependências da Penitenciária Wellington Rodrigo Segura de Presidente Prudente, destinadas ao seu companheiro DOUGLAS, que se encontrava recluso naquele estabelecimento prisional, a fim de ser entregue ao consumo alheio.

De acordo com a acusação, ao receberem a encomenda na Penitenciária Wellington Rodrigo Segura de Presidente Prudente, os agentes penitenciários constataram que no seu interior estavam camufladas em massa de biscoito as porções de maconha supra descritas, as quais o denunciado DOUGLAS admitiu ter combinado que o seu companheiro FABIANO as remetesse à unidade prisional.

Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, somada à apreensão de grande quantidade de maconha, afigura-se quadro seguro a apontar que a droga apreendida seria destinada à entrega a consumo alheio ou à venda no interior do estabelecimento prisional, em concurso de agentes entre os denunciados.

Notificado, o acusado DOUGLAS apresentou defesa prévia (fls.190/191), reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual.

Notificado, o acusado FABIANO apresentou defesa prévia (fls.194/195), e requereu a concessão da justiça gratuita e a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia.

Por decisão datada de 20 de maio de 2022, a denúncia foi recebida, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, e determinada a citação dos réus (fls. 212/216).

Citados, os acusados compareceram na audiência.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogados os acusados. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A defesa do réu Fabiano Robles de Lima, em memoriais (fls. 273/283), alegou a ocorrência de erro de tipo ante o desconhecimento acerca do conteúdo do pacote. Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da pena no patamar mínimo, fixação do regime inicial mais brando e substituição da pena privativa por restritiva de direito.

A defesa do réu Douglas Ricardo de Oliveira, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado (fls. 284/292), em especial a ausência de provas para condenação. Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando e substituição da pena privativa por restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5),

pelo auto de exibição/apreensão (fl. 6), pelo laudo pericial (fls. 14/16), pelo documento de fls. 51/96, bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A autoria é certa e incide sobre os réus.

A testemunha Edilan Dias da Silva, agente penitenciário, disse em juízo que trabalha no setor que recebe sedex. Relatou que quando chega o sedex é passado pelo scanner, que chegando na inclusão realizam uma lista de chamada dos presos participantes. Ainda, mencionou que chamam o preso participante no raio, que se deslocam até a inclusão, confirmando os dados do preso e o endereço do visitante. Explicou que quando abriram o sedex, tinha um pacote de bolacha aparentando estar modificado. Em relação a esse pacote disse que estava com droga, aparentando ser maconha. Informou que não foi ele que abriu o sedex, mas que nunca ocorreu situação semelhante. Mencionou que comunicaram o preso, que presenciou o ocorrido. Além disso, relatou que Douglas disse que era visitante dele, confirmando os dados de Fabiano e que também constava no cadastro. Afirmou que no cadastro constava Fabiano como companheiro de Douglas. Sobre as pessoas que têm autorização para enviar sedex, explicou que os visitantes têm que ser cadastrados antes, com autorização do preso que tem que mandar um pedido, devendo o visitante confirmar todos os dados e documentos. Ademais, mencionou que precisa passar no setor para ser aprovado, e, então emitir a carteirinha. Alegou que tem que ser cadastrado para enviar alguma coisa para o preso, que carteirinha vencida ou endereço errado também não recebe. Narrou que a caixa é lacrada pelo visitante, que confirmam todos os dados com o preso antes de abrir. Negou ser comum receberem esse tipo de sedex com droga. A respeito dos sedex informou que pegam dois ou três em um ano, mas que já aconteceu de alguém tentar fazer maldade. Descreveu que a embalagem estava deformada, que era uma bolacha tipo pão de mel e que apresentaram para o preso que estava muito mal feito, com o que ele concordou.

A testemunha Luís Carlos Stuqui, agente penitenciário, disse em juízo que no dia chamaram o Douglas para entregar um sedex. Explicou que antes de entregarem o sedex costumam realizar uma averiguação, bem como confirmam se a pessoa é visitante do preso. Sustentou que somente as pessoas cadastradas e autorizadas pelo próprio detento podem encaminhar correspondência. Alegou que no cadastro consta que Fabiano é companheiro de Douglas. Disse que após terem localizado a droga encaminharam Douglas para o setor de disciplina.

Ouvida na condição de informante, Kátia Zillig Branco disse que é cunhada de Fabiano. Relatou que se conhecem há 14 anos, que não tem conhecimento que Fabiano esteja envolvido com droga. Informou que houve uma obra na residência de Fabiano, que estava trabalhando como ajudante do pai, estando na casa ela e o filho. Mencionou que no dia Fabiano estava com uma caixa para levar ao correio, mas que antes chegou uma pessoa com um carro e o chamou. Negou conhecer essa pessoa, que apenas chamou Fabiano. Explicou que o rapaz colocou a caixa de Fabiano no carro, que o rapaz iria enviar o sedex para ele. Relatou que Fabiano não conhecia o rapaz. Por fim, explicou que foi uma surpresa para Fabiano e que após retornou o serviço na obra.

Interrogado em juízo, Douglas Ricardo de Oliveira disse que não foi o funcionário que achou a "situação" do sedex, mas sim um detento que trabalha no setor. Relatou que tinha um amigo chamado Jeferson que ficou de encaminhar o sedex para ele. Informou que forneceu os dados de Fabiano e que Jeferson foi até sua casa. Explicou que se Fabiano soubesse da "situação" do sedex não teria postado no correio. Afirmou que tinha um relacionamento com Fabiano. Negou ter sido ouvido pelo Delegado. Foi ouvido apenas na sindicância. Mencionou que Jeferson remeteu o entorpecente, mas que o Fabiano não tinha conhecimento. Narrou que Jeferson estava preso com ele, que combinaram a postagem. Ainda, disse que dois dias após ter saído da penitenciária Jeferson foi até a casa de Fabiano, pois tinha entregado o endereço. Narrou que Jeferson e Fabiano foram até o correio com a caixa lacrada para fazer a postagem. Afirmou que não disse para Fabiano que Jeferson iria atrás dele. Explicou que Fabiano achava que o sedex continha roupas e coisas de comer. Negou fazer parte da Facção Criminosa Bonde do Cerol Fininho. Alegou que Jeferson fez o serviço no pacote de bolacha. Negou que Fabiano tinha conhecimento. Relatou

que combinou com Jeferson. Na sequência disse que só Fabiano tinha cadastro para fazer a encomenda chegar até ele. Por fim, disse que mantém o relacionamento com Fabiano há mais de três anos, mas que em 2017 não tinham ainda o relacionamento. Interrogado em juízo, o réu Fabiano Robles de Lima disse que tem 34 anos, foi processado por um crime de tráfico. Relatou que era companheiro de Douglas. Aduziu que não estava sabendo do fato. Disse que o Jeferson pediu que enviasse um pacote pelo correio, pois era a única pessoa que podia enviar. Informou que foi enviar a caixa e disse que foi o Douglas que pediu para enviar o pacote. Aduziu que não chegou a falar com Douglas. Relatou que não deu tempo de ver o que continha na caixa, pois foi muito próximo do horário do correio fechar. Afirmou que tinha um relacionamento com o Douglas. Disse que ficou sabendo do homicídio que Douglas cometeu para a facção criminosa. Aduziu que Jeferson pediu para enviar uma caixa para Douglas pois afirmou que era uma ajuda pelo que Douglas fez para ele no passado. Disse que já chegou a visitar Douglas no presídio. Narrou que as condições do presídio eram precárias. Relatou que os envios eram importantes para os presidiários terem uma condição de vida mais digna. Jeferson mostrou a caixa dentro de seu carro. Disse que a caixa já estava lacrada. Afirmou que não conhecia o Jeferson, nem de vista. Informou que Jeferson conhecia Douglas. Disse que Jeferson foi procurado por Douglas para o envio da caixa e Jeferson disse que a única pessoa que pedia enviar a caixa era Fabiano. Parecia que Jeferson tinha realmente o intuito de ajudar Douglas. Disse que ficou sabendo que a caixa tinha drogas por meio de um advogado. Relatou que recebeu muitas correspondências de Douglas. Informou que Douglas pediu desculpas nas mensagens das correspondências. Relatou que o procedimento para enviar a caixa era rápido. Disse que não tem cadastro para enviar as correspondências, mas quem pode receber é somente quem está com o nome no rol. Aduziu que tem que comprovar o vínculo que tem com a pessoa para enviar a correspondência.

Pois bem, com base em toda a prova angariada no decorrer da instrução, fica patente a responsabilidade penal dos réus Douglas Ricardo de Oliveira e Fabiano Robles de Lima pelo crime de tráfico de drogas.

É cediço que no processo penal por tráfico, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido, ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal.- O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). No caso dos autos, os agentes penitenciários relataram, em essência, a apreensão de oito porções de maconha encaminhadas via correios (Sedex nº QB 41802171 3 BR), remetidas em nome do réu Fabiano e cujo destinatário era o corréu Douglas.

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas, conferindo-se, pois, valor probatório aos depoimentos dos agentes penitenciários.

De resto, não é razoável supor cometimento de denúncia caluniosa, servindo a Polícia Penal como instrumento de ilícito contra a Administração da Justiça. O modo como estava acondicionado o entorpecente (camuflado no interior de um pacote de bolachas) e toda a quantidade partilhada da droga (301,27g de maconha, em oito porções), bem como as circunstâncias da apreensão (engodo para introdução de relevante quantidade de entorpecentes na unidade prisional) levam à inexorável conclusão de que toda a droga era mesmo destinada ao tráfico, sendo incogitável afirmar que destinava-se ao consumo pessoal do réu Douglas.

Aliado a isso, o réu Douglas Ricardo de Oliveira confessou a prática do delito, admitindo que acordou com terceiro de nome Jeferson o envio das drogas por meio de Fabiano, sem que este último tenha tido ciência do conteúdo da remessa. Mesmo que ele não tenha chegado à posse direta do entorpecente, já que impedido pela fiscalização na unidade, confessou ser o destinatário da encomenda e ter conhecimento de que em seu interior havia drogas. Destarte, o acordo de vontades em negociação anterior é suficiente para caracterizar a conduta do verbo "adquirir", previsto no tipo legal.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. DELITO UNISSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. 2. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. (...) (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.384.292 - MG, RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe: 17/03/2020).

Já quanto ao réu Fabiano Robles de Lima, importa ressaltar que o suposto (e inverossímil) desconhecimento acerca da natureza ilícita da encomenda não afasta sua responsabilidade penal.

Tendo por vários anos um companheiro presidiário, é certo que possui ciência do burocrático procedimento para o cadastro de visitantes na unidade prisional, únicas pessoas habilitadas para o envio de correspondência aos internos.

Aliás, o único registro em sua certidão de antecedentes criminais (fls. 179/180) trata exatamente de uma denúncia pelo crime de tráfico de drogas praticado de forma muito semelhante à ora narrada - ingresso de entorpecentes no sistema prisional via correspondência de detento. É dizer, o réu tem pleno conhecimento das razões pelas quais a penitenciária imprime tamanho controle sobre os remetentes dos objetos.

Aliado a isso, tem-se a suspeita sequência de eventos narrados pelo réu Fabiano em juízo: um terceiro que até então desconhecia (e que não fez questão de conhecer) o abordou e solicitou o envio urgente de um pacote a seu companheiro preso, de conteúdo não identificado (e que não fez questão de identificar) e destinado a Douglas, pessoa que ele sabe pertencer ou possuir relações com facção criminosa. Por fim, observa-se no ofício juntado a fls. 08/12 que na data de 26/08/2021 - dois dias após o envio da correspondência - o acusado Fabiano Robles de Lima escreveu mensagem a Douglas informando que depositaria dinheiro para que ele comprasse o que não foi possível incluir na caixa do Sedex (fl. 10), indicando que fora ele o responsável pelo acondicionamento do conteúdo.

Destarte, o erro de tipo aventado pela defesa do acusado exige total desconhecimento acerca da ilicitude do fato, o que não se verifica neste caso. É o entendimento pacífico do TJSP:

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Ingresso em presídio - Quantidade relevante de entorpecente - Prova segura e suficiente - Absolvição inviável - Materialidade e autoria comprovadas - Conduta que se amolda ao art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 - Condenação que se impunha - Prova cabal a demonstrar que a recorrente trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico - Erro de tipo - Falta de comprovação - Inocorrência - Sem notícia nos autos de que a ré integre organização criminosa - Pena privativa de liberdade adequada - Regime

aberto que se mantém - Reconhecimento da benesse da redutora - Inexistência de recurso da Acusação - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1500639-62.2021.8.26.0630; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia; Data do Julgamento: 27/03/2022; Data de Registro: 27/03/2022)

Evidente, dado o panorama exposto, que o réu Fabiano Robles de Lima, se não tinha conhecimento sobre a ilicitude do conteúdo da remessa - hipótese muito improvável -, certamente assumiu o risco de tal, agindo com dolo eventual nos termos do art. 18, inciso I (segunda parte), do Código Penal, devendo responder pelo delito, nos termos do art. 13 do mesmo diploma legal.

Nesse diapasão, o conjunto probatório amealhado nos autos é robusto a demonstrar a conduta dolosa dos réus.

Importante ressaltar que a configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando tão somente a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, informadas com o escopo final de entregar a droga para venda e consumo alheio.

A respeito:

"Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de 'trazer consigo'." (TJ-SP - APL: 00666514620128260114 SP 0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2014 - grifei).

No presente caso, como referido, foi apreendida droga escondida no interior de correspondência encaminhada pelo réu Fabiano e destinada ao corréu Douglas, o qual se encontra recolhido em estabelecimento prisional, estando, portanto, devidamente caracterizado o tráfico de entorpecentes, com a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 (infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional).

Portanto, o conjunto probatório coligido aos autos é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação dos réus Douglas Ricardo de Oliveira e Fabiano Robles de Lima, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo.

Desse modo, ante a condenação pelo crime previsto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, passo a dosar as penas dos réus, atendendo ao método trifásico.

Réu Fabiano Robles de Lima

Na primeira fase de aplicação da pena, analisadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, bem como o relativo ao art. 42 da Lei 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar sua conduta social, sendo que pouco se colheu a respeito de sua personalidade.

O motivo do crime, ao que se percebe, é aquele próprio do tipo em análise, qual seja, desejo de obtenção de lucro fácil mediante a disseminação do uso de drogas. Não se depreende dos autos circunstâncias e consequências a importarem maior gravidade da conduta criminosa.

O réu não possui antecedentes criminais.

O comportamento da vítima não incide na espécie, já que cometido o delito em face da coletividade (saúde pública) como um todo.

Ainda, a natureza e a quantidade da droga não impõem maior reprovabilidade na conduta do réu.

Assim, diante das circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a considerar, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 (infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional), razão pela qual elevo a pena em 1/6 e a fixo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Há também de se considerar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de réu primário e ostentar bons antecedentes, aliada à pequena quantidade de droga apreendida (301,27g de maconha), revelando tratar-se de pequeno traficante, motivo pelo qual reduzo a pena na proporção de 2/3. Em razão disso, torno definitiva a pena do réu em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão.

Proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, fixo a pena de multa em 191 (cento e noventa e um) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver nos autos provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu.

Considerando o caso dos autos, em que o acusado não possui maus antecedentes, aliada à pequena quantidade dos entorpecentes apreendidos, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como de conceder a suspensão condicional da pena por entender que não são suficientes para a reprovação do delito praticado, em franco prejuízo à saúde e segurança pública.

Réu Douglas Ricardo de Oliveira

Na primeira fase de aplicação da pena, analisadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, bem como o relativo ao art. 42 da Lei 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar sua conduta social, sendo que pouco se colheu a respeito de sua personalidade.

O motivo do crime, ao que se percebe, é aquele próprio do tipo em análise, qual seja, desejo de obtenção de lucro fácil mediante a disseminação do uso de drogas.

Não se depreende dos autos circunstâncias e consequências a importarem maior gravidade da conduta criminosa.

O réu ostenta maus antecedentes criminais, ante as condenações definitivas nos processos 0000368-49.2010.8.26.0037 (fls. 144), 0005822-83.2005.8.26.0037 (fls. 144), 0009600-61.2005.8.26.0037 (fls. 144), 0011887-31.2005.8.26.0037 (fls. 144), 0014078-49.2004.8.26.0037 (fls. 145), 0021059-94.2004.8.26.0037 (fls. 145), 0021796-87.2010.8.26.0037 (fls. 145) e 0029083-38.2009.8.26.0037 (fls. 145), ficando as demais para serem valoradas exclusivamente na fase seguinte, pois caracterizadoras de reincidência.

O comportamento da vítima não incide na espécie, já que cometido o delito em face da coletividade (saúde pública) como um todo.

Ainda, a natureza e a quantidade da droga não impõem maior reprovabilidade na conduta do réu.

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior

desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, diante dos maus antecedentes do acusado, fixo a pena-base um pouco acima do patamar mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, ante as condenações definitivas nos processos 1502641-76.2019.8.26.0047 (fls. 146) e 0008266-22.2011.8.26.0153 (fls. 148). De outro lado, à luz da súmula 545 do STJ, incide a atenuante da confissão. Desse modo, por serem preponderantes, compenso a atenuante em comento com a agravante da reincidência em relação à condenação no processo 1502641-76.2019.8.26.0047. Remanesce a agravante da reincidência em face da condenação no processo 0008266-22.2011.8.26.0153, razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária do réu em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 (infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional), razão pela qual elevo a pena em 1/6 e fixo a pena definitiva do réu em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão. Aqui, ressalta-se que o réu não faz jus ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois como mencionado acima, é multirreincidente e portador de maus antecedentes.

Assim sendo, torno definitiva a pena do réu no patamar de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

Proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, fixo a pena de multa em 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver, nos autos, provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal. Além da pena aplicada ser superior a oito anos, o art. 33, § 3º, do CP, dispõe que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código", e, no presente caso, está-se diante de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, com nada menos que dez condenações com trânsito em julgado, o que revela sua alta periculosidade para a sociedade, pois nítida a intenção de continuar a delinquir, em franco prejuízo à segurança pública. Incompatível, pois, a fixação de regime mais brando.

Tendo em vista o montante da pena aplicada, é incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

1) CONDENAR o réu FABIANO ROBLES DE LIMA a cumprir, em regime inicial aberto, a pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, bem como a pagar 191 (cento e noventa e um) dias-multa, em seu valor mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06;

2) CONDENAR o réu DOUGLAS RICARDO DE OLIVEIRA a cumprir, em regime inicial fechado, a pena privativa de liberdade consistente em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, bem como a pagar 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em seu valor mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Presentes os requisitos objetivo (artigo 313, I, do CPP) e subjetivo (risco evidente à ordem pública, vez que reincidente em crimes gravíssimos mediante emprego de violência à pessoa), materializado no artigo 312 do Código de Processo Penal, determino a prisão cautelar do acusado DOUGLAS RICARDO DE OLIVEIRA, de modo que não poderá recorrer em liberdade. Recomendo-o no estabelecimento em que já se encontra, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.



Quanto ao acusado FABIANO ROBLES DE LIMA, em razão do regime de cumprimento e quantidade de pena aplicados, pelo fato de ter permanecido solto durante a instrução e, principalmente, por estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 e 313, do CP), possível que, apresentando recurso, possa fazê-lo em liberdade.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Finalmente, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03; ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da justiça gratuita, que ora concedo aos acusados. Anote-se.

Em caso de recurso, expeça(m)-se guia(s) de execução provisória.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- 1) Atualize-se o histórico de partes;
- 2) Comuniquem-se o IIRGD e o Juízo Eleitoral;
- 3) Expeçam-se guias de execução definitiva ou, sendo o caso, ofícios de aditamento às guias de execução;

P. Int.

Presidente Prudente-SP, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA